

1500395-16.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2071039/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23602276 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2071039 - DISE- DEL.SEC.JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

DOUGLAS PEREIRA DA SILVA, e outros

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500395-16.2022.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2071039/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23602276 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2071039 - DISE- DEL.SEC.JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

DOUGLAS PEREIRA DA SILVA, e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

DOUGLAS PEREIRA DA SILVA está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notificado (fls. 170), o réu apresentou defesa (fls. 173/180).

A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2022 (fls. 181/182) e o réu foi citado

(fls. 217).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 254).

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado. A defesa teceu considerações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 4/7), boletim de ocorrência (fls. 19/24), auto de exibição e apreensão (fls. 27/29), fotografias (fls. 43/65), informação (fls. 221), laudos periciais (fls. 114/121, 141/144, 145/150, 151/158, 159/164, 236/246, 247/248, 249/253), além da prova oral colhida na fase instrutória.

A autoria é certa.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do delito e disse que havia começado a vender entorpecentes cerca de 15 dias antes de sua prisão, por conta de dificuldades financeiras. Conheceu uma pessoa enquanto trabalhava com reciclagem, que lhe repassou as drogas e as demais substâncias que estavam em sua posse, as quais utilizava para "enfraquecer" a cocaína. Sua sogra, proprietária do veículo, não tinha conhecimento de que ele estava sendo usado para o comércio espúrio. Não chegou a efetivar o pagamento das drogas, que tinham valor estimado de R\$1.500,00.

O policial militar Caique relatou que, durante patrulhamento, avistou o veículo do réu estacionado em um ponto de tráfico, enquanto um adolescente (Jean) estava debruçado, pelo lado de fora, junto ao vidro do motorista. Como a rua estava deserta, desconfiou da situação e procedeu à abordagem de ambos. Em revista pessoal, verificou que o adolescente tinha R\$45,00 e dois eppendorfs brancos de cocaína e o acusado estava com R\$25,00. No banco traseiro do veículo, encontrou uma sacola preta contendo diversas drogas ilícitas, embalagens vazias, além de R\$810,00 e dois aparelhos celular. Na ocasião, Douglas confessou que estava vendendo entorpecentes, por atravessar dificuldades financeiras, e indicou que em sua casa havia mais substâncias ilícitas. Na residência do réu, ele apontou que as drogas estavam em um banheiro desativado, onde foi encontrada uma substância possivelmente utilizada para misturar na cocaína, mais porções brutas de cocaína, embalagens vazias, balança de precisão e outras substâncias ilícitas. Nunca havia abordado o réu anteriormente.

O policial militar Rodrigo confirmou, em linhas gerais, o depoimento de seu colega e acrescentou que o acusado externou comportamento diverso do que rotineiramente costuma observar entre traficantes experientes.

A sogra do réu, Alzira, narrou que é proprietária do veículo apreendido com o réu e que não sabia que ele estava sendo utilizado para fins ilícitos.

A testemunha Flavio contou que conhece Douglas há mais de 10 anos e teceu bons comentários acerca da sua conduta, bem como que nunca notou movimentação atípica na residência dele.

A testemunha Felipe disse que conhece o réu há vários anos e que não tem conhecimento de que ele estivesse envolvido com o comércio espúrio.

Pois bem. O réu admitiu o tráfico sob o crivo do contraditório, oportunidade em que

sustentou atravessar dificuldades financeiras. No mesmo sentido, as narrativas apresentadas pelos policiais militares, que apreenderam significativa quantidade e variedade de entorpecentes na posse do acusado, incompatíveis com o mero consumo próprio.

Nesta senda, nada há nos autos a afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares colhidos durante a instrução ou da confissão judicial do acusado. Nesse sentido: "Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrimSP 93/239).

A alegação de dificuldade financeira, ainda que verdadeira, não tem o condão de afastar o decreto condenatório, já que o acusado é apto para o trabalho e deveria ter buscado meios lícitos para incrementar o seu sustento, inclusive porque mencionou possuir uma fonte de renda lícita.

Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor do acusado, que não trouxe elementos a infirmá-lo. E, ainda que ele também seja usuário, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem.

Sobre o tema, veja-se:

"TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)."

Nesta toada, de rigor a condenação.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, verifico, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, que a pena-base deve ser majorada, considerando a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos. Assim, fixo-a acima do mínimo legal em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão e a agravante descrita no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, mantenho a pena no patamar anterior.

Por fim, a despeito das alegações ministeriais, aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, à mingua de segura comprovação de que o réu se dedicasse às atividades criminosas por tempo considerável ou integrasse organização criminosa.

Todavia, cumpre observar que referido preceito legal fixa os requisitos necessários

à sua aplicação, mas não estabelece parâmetros para escolha do quantum de diminuição a ser extraído entre as frações de 1/6 e 2/3. A esse respeito, oportuna a citação do Exmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luiz Fux, esposada em seu voto no Habeas Corpus nº 111.097-MG:

“Destarte, se se entender pela ocorrência de bis in idem em decorrência da consideração das circunstâncias atinentes à quantidade e à qualidade da droga na majoração da pena-base e na dosagem da minorante do § 4º da Lei de Drogas, o magistrado ficará sempre adstrito à aplicação da minorante na fração máxima, tornando letra morta o preceito legal que determina seja ela aplicada na forma escalonada, por isso, a conclusão há de ser pela ausência de sobreposição, notadamente porque a pena-base e a minorante têm finalidades distintas: a primeira encontra justificativa na sanção necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, e a segunda visa a contemplar, com o abrandamento da punição, não necessariamente com a fração máxima de 2/3, o agente primário e de bons antecedentes que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Nesse sentido: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO INSTRUMENTO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. QUANTUM DE REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGAS. MENOR FRAÇÃO. 1. O legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, deixando de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e maior frações indicadas para a mitigação, disciplinando a doutrina e a jurisprudência que devem ser consideradas as circunstâncias previstas no art. 59 do e Supremo Tribunal Federal especialmente o disposto no art. 42 da Lei Antitóxicos. 2. Juízo de proporcionalidade que admite a aplicação do redutor no percentual mínimo de 1/6, de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do CP, dada a quantidade e a espécie de entorpecente encontrado em poder do acusado. 3. Não há bis in idem na consideração da quantidade de droga para agravar a pena-base e para negar a redução a maior na terceira etapa da dosimetria, mas apenas a utilização de um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, objetivando a aplicação de reprimenda proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (STJ, AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.403.921-MG – 2011/0085663-6 – 6ª T – rel. Ministro Vasco Della Giustina, 23.08.2011, v.u.).

Portanto, em virtude da quantidade de entorpecentes apreendida, reduzo a pena de 1/2 para 3 anos de reclusão e 300 dias-multa.

Assim, a reprimenda acima fixada torna-se definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição.

Considerando a primariedade do réu (fls. 21/213), fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, e considerando, ainda, os motivos esposados na primeira fase.

Finalmente, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, “caput”, da CF)”(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim, por entender que o art. 387, §2º, CPP viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu DOUGLAS PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 300 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado respondeu ao processo preso e não poderá apelar em liberdade, tendo em vista que continuam presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, notadamente em virtude da necessidade de impedir a reiteração criminosa. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Determino o perdimento dos objetos, do veículo e do dinheiro apreendidos com o acusado, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06.

Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Jaú, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA